

1500103-17.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... autos a existência de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de fabricação. 5. Ordem concedida." (HC 100.946/GO, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. 25/10/2011, DJe 27/02/2012).

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500103-17.2022.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-17.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013735/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 22468034 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 77/22/925 - 2º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2013735 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 77/22/925 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON HENRIQUE FAVARELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

MAYCON HENRIQUE FAVARELLI, qualificado a fls.27, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput e §1º, inciso I, e artigo 34, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 19h30, na esquina da Rua do Chá com a Rua da Borracha, altura do nº 116, no Jardim Pérola, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, trazia consigo e transportava, no

interior do veículo Honda/Civic, placas DXF-9819-Cosmópolis/SP, 98 (noventa e oito) porções de cocaína, com cerca de 20,0g e, 21 (vinte e uma) porções Cannabis sativa L, popularmente conhecida por "maconha", com cerca de 31,0, bem como guardava, tinha em depósito e ocultava, em sua residência situada na Rua do Chá, nº 138, 01 (uma) porção de cocaína, com cerca de 4.700,0g; 02 (dois) tijolos de "maconha", com cerca de 607,0g; e, mais 01 (uma) porção de "maconha", com cerca de 20,0g (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 19/21 e auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes a fls. 22/23), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que na mesma data e horário, na residência situada na Rua do Chá, nº 138, no Jardim Pérola, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, o réu supracitado, possuía e guardava, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, mais precisamente, 02 (duas) facas de cozinha com resquícios de drogas; 06 (seis) tigelas plásticas com resquícios de drogas; 01 (uma) tesoura com resquícios de drogas; 01 (uma) peneira com resquícios de drogas; 02 (dois) medidores com resquícios de drogas; 02 (duas) balanças de precisão, das marcas Clink e Fênix, com resquícios de drogas; 01 (um) liquidificador; 09 (nove) pacotes com embalagens; 03 (três) rolos de plásticos para embalagens; e 01 (um) rolo de fita adesiva (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 19/21), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no item "2", nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, o réu supramencionado, tinha em depósito e guardava, ainda que gratuitamente, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, mais especificamente, 7.570g (sete quilos, quinhentos e setenta gramas) de "pó branco", fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas no item "1", das quais, uma parte era transportada no veículo referido para distribuição aos pontos de comercialização e entrega a consumo de terceiros e, outra parte maior, era mantida em sua residência, onde também mantinha os objetos/instrumentos e insumo destinados ao preparo e embalagem de drogas.

Ocorreu que, guardas municipais receberam denúncia anônima dando conta que o veículo Honda/Civic, cor preta, placas DXF-9819, de Cosmópolis, estaria realizando a entrega de drogas numa lanchonete conhecida como "Bar da Laura" e que o indivíduo que realizaria a entrega residia na Rua do Chá.

Assim é que, visando verificar a denúncia anônima, os agentes passaram a patrulhar pelas imediações e, na esquina da Rua do Chá com a Rua da Borracha, avistaram e interceptaram a frente do veículo Honda Civic citado, o qual era conduzido pelo indiciado. Os guardas tentaram forçar a parada do réu colocando a viatura à sua frente, mas o denunciado acionou marcha a ré, jogando o carro contra o guarda municipal Lacerda que, por sua vez, efetuou disparos de arma de fogo contra os pneus dianteiro e traseiro esquerdo do veículo.

Em seguida, MAYCON, mesmo com os pneus estourados, tentou se evadir com o veículo, mas acabou se chocando contra a lixeira e o muro da residência de nº 116. Em seguida, o denunciado dispensou, no assoalho do lado do passageiro do carro, um kit contendo drogas.

Realizada a busca no veículo, os agentes localizaram 98 (noventa e oito) porções de cocaína e 21 (vinte e uma) porções de "maconha".

Ante à localização das drogas, os guardas questionaram MAYCON se em sua residência

havia mais drogas. O indiciado inicialmente negou, mas após acabou admitindo a existência de drogas em sua casa e indicou um dos quartos como sendo o local onde as drogas estavam guardadas.

Assim é que, os guardas se dirigiram a residência do indiciado e, sobre a mesa, localizaram 01 (uma) porção de maconha a "granel", uma tigela contendo resquícios de cocaína e um medidor de plástico.

No quarto indicado anteriormente por MAYCON, localizaram uma bacia plástica contendo 01 (uma) porção de cocaína e alguns sacos plásticos contendo 01 (uma) porção de cocaína, com cerca de 4.700,0g (quatro quilos e setecentos gramas), bem como 7.570,0g (sete quilos quinhentos e setenta gramas) de pó branco utilizado para preparo da cocaína, 02 (dois) tijolos de "maconha", com cerca de 607,0 gramas e, ainda, diversas embalagens plásticas para acondicionamento de drogas, facas, tesoura, plástico para acondicionamento de droga, duas balanças, um liquidificador e uma peneira.

Ainda no interior do imóvel, dentro do armário da cozinha, foi encontrada a importância de R\$ 1.200,00, em espécie. No imóvel também foi encontrada 01 (um) caderno com manuscritos relacionados ao comércio de drogas (consoante auto de exibição e apreensão de fls. 19/21).

Indagado pelos agentes público, MAYCON confessou o delito, afirmando que era o responsável pelo armazenamento, distribuição das drogas e recebimento do dinheiro. Entretanto, interrogado na Delegacia de Polícia, optou por permanecer em silêncio.

Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a grande quantidade, a forma de acondicionamento, o encontro de dinheiro, bem como a confissão informal e o comportamento do indiciado, aliados ao relato dos guardas municipais noticiando a existência de denúncia anônima que apontava o tráfico de drogas pelo indiciado, evidenciam que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls.195) e apresentou defesa preliminar (fls.127/128). A denúncia foi recebida em 16 de Fevereiro de 2022 (fls. 181/182). E o réu foi citado (fls.198). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum e interrogado o acusado ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência da ação, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, ou, em caso de condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a fixação da pena base no mínimo legal e substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.15/18, auto de exibição e apreensão de fls.19/21, auto de constatação preliminar de fls.22/23, laudo de entorpecentes fls. 204/206, laudo de apetrechos de fls.207/210 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Humberto Assis de Lacerda e Jairo José dos Santos deram versões uníssonas a respeito dos fatos. Disseram que receberam denúncias anônimas apontando a pessoa do acusado como sendo o responsável pelo abastecimento de uma

biqueira na Rua Belém com a Rua Maceió, e que ele preparava a droga na sua residência da Rua do Chá. Que ele fazia o transporte num veículo Honda Civic. Que de posse destes dados foram averiguar, e se depararam com o veículo do acusado na esquina da rua do Chá. Que foi dado ordem de parada, mas ele desobedeceu, dando ré e jogando o carro contra o guarda Humberto. Que foi necessário disparar dois tiros no pneu, e o acusado mesmo assim tentou fugir, e então colidiu com uma lixeira e a grade do portão. Foi abordado e dentro do veículo havia um pacote contendo 98 porções de cocaína e 28 porções de maconha. Que na casa dele, na cozinha, havia porções de maconha, tigela contendo resquícios de cocaína e um medidor plástico. No quarto havia uma bacia plástico contendo porções de cocaína, sacos plásticos, pó branco utilizado para mistura, tijolos de maconha, além de embalagens plásticas, facas, tesoura, plástico para acondicionamento de droga, duas balanças, liquidificador e uma peneira. No armário havia R\$ 1200,00 em dinheiro. Que o acusado confessou os fatos, dizendo que preparava a droga e fazia o abastecimento na biqueira.

Tamires Franciele Aquino Gomes, cunhada do acusado, disse que ele é usuário de cocaína e que sempre ajudava com as despesas da casa. Que a mãe tinha uma loja e ele vendia boné e camiseta para ajuda-la. Que na pandemia eles passaram por dificuldades financeiras, e a genitora do acusado ficou doente, com câncer..

O acusado, em seu interrogatório, narrou que estava devendo para traficantes, pois era usuário de cocaína, e também estava com dificuldades financeiras em casa, já que a mãe ficou doente e não conseguia mais trabalhar. por conta disso, aceitou olhar a casa para o traficante, sem mexer em nada. Que não morava no local, apenas ficava olhando. Que o traficante pediu para ele levar a droga para outro local no veículo, mas não era numa biqueira, e acabou sendo abordado pelos guardas municipais. Que ficou nervoso, por isso deu ré no veículo. Tem 22 anos e nunca foi preso nem processado.

A versão trazida a Juízo, em que o réu busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime de tráfico e posse dos petrechos e da matéria prima, encontra-se em total divergência com todas as demais provas coletadas, o que torna a alegação desprovida de elementos que a consubstancie, eis que a quantidade de droga apreendida, a variedade e a quantidade de materiais destinados ao embalamento e preparo da droga bem revelam seu profundo envolvimento com o comércio de drogas.

De se esclarecer que os guardas municipais já tinham recebido denúncia anônima indicando o acusado como o responsável pelo preparo da droga e abastecimento da biqueira, e acusado, quando abordado, confessou este fato, sendo que a localização de todo o material apreendido, com as circunstâncias da abordagem, em pleno ato de transporte de droga, só reforçam esta confissão informal.

E não há porque duvidar das alegações dos guardas municipais, pois não se verificou, em nenhum momento, eventual desavença entre eles ou mesmo a intenção destes agentes em prejudicar uma pessoa inocente. E os depoimentos foram firmes, uníssonos e imparciais, e são aptos a ensejar um decreto condenatório, pois nada indica que mentiram em Juízo, ao contrário do acusado, que tem intenção de apresentar versão exculpatória para livrar-se de uma condenação, ainda que esta seja totalmente inverossímil.

Ademais, os depoimentos destes agentes se mostraram harmônicos e seguros, demonstrando idoneidade, razão pela qual confiro plena credibilidade para firmar meu convencimento.

E a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância do depoimento de policial militar, quanto mais se não existe nenhum elemento nos autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

“PROVA. Depoimento policial. Valor. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas. Análise que se faz em cada caso concreto. O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho. A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal Recurso improvido neste aspecto” (Apelação Criminal n.993.08.043553-7, São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 09.09.08 V.U. Voto n. 5652).

“PROVA. Depoimento de policial. Validade. Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado. Eficiência. Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva. Ocorrência - Apelação provida parcialmente” (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 São Paulo 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal Relator: René Nunes 28.02.07 M.V. Voto n. 10.200).

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade, ou seja, 98 (noventa e oito) porções de cocaína, com cerca de 20,0g e, 21 (vinte e uma) porções Cannabis sativa L, popularmente conhecida por “maconha”, com cerca de 31,0, bem como guardava, tinha em depósito e ocultava, em sua residência situada na Rua do Chá, nº 138, 01 (uma) porção de cocaína, com cerca de 4.700,0g; 02 (dois) tijolos de “maconha”, com cerca de 607,0g; e, mais 01 (uma) porção de “maconha”, com cerca de 20,0g (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 19/21 e auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes a fls. 22/23), entendo bem comprovada à prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. A condenação é medida que se impõe.

Destaca-se que possuir em depósito insumos destinados para a fabricação de entorpecentes é crime tipificado no artigo 33, §1º, I da Lei 11.343/06, e o acusado foi encontrado na posse de um pó químico branco, conforme laudo de fls. 204/206 usado na preparação da cocaína.

Também restou caracterizado o crime previsto no artigo 34 da mesma lei, pois os objetos encontrados na residência do acusado, ou seja, 02 (duas) facas de cozinha com resquícios de drogas; 06 (seis) tigelas plásticas com resquícios de drogas; 01 (uma) tesoura com resquícios de drogas; 01 (uma) peneira com resquícios de drogas; 02 (dois) medidores com resquícios de drogas; 02 (duas) balanças de precisão, das marcas Clink e Fênix, com resquícios de drogas; 01 (um) liquidificador; 09 (nove) pacotes com embalagens; 03 (três) rolos de plásticos para embalagens; e 01 (um) rolo de fita adesiva (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 19/21) são itens

utilizados para o embalo e comercialização de drogas.

Mas com relação à posse da matéria prima, insumos e dos petrechos, previstos naqueles artigos, impõe-se a aplicação do princípio da consunção.

Este princípio estabelece que na hipótese de uma conduta consistir em meio necessário ou preparatório para consumação de outro delito, acaba por este absorvida, implicando no esvaziamento da norma incriminadora a ponto de possibilitar a ocorrência de um único fato típico.

Sobre o princípio da consunção, preconiza Damásio E. de Jesus que “ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa” (in Direito Penal; 1º volume – Parte Geral, 26ª edição, Ed. Saraiva: 2003, p. 114).

No caso dos autos, os insumos e os objetos foram apreendidos na residência no mesmo contexto fático da prática do delito de tráfico de drogas, é dizer, serviam claramente como meio para finalidade da comercialização de substâncias entorpecentes, existindo, portanto, tão-somente o delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

É como ensina Luiz Flávio Gomes:

“Cuida-se de delito subsidiário, ou seja, praticando o agente, no mesmo contexto fático, tráfico de drogas e de maquinários, deve responder apenas por aquele, ficando este absorvido (o que não impede o juiz de considerar essa circunstância na fixação da pena). Nesse sentido: “Embora se trate de condutas previstas em dispositivos legais distintos (arts. 12 - atual art. 33 - e 13 - atual art. 34), comete somente o delito de tráfico o agente que, no mesmo contexto fático, é surpreendido mantendo sob seu poder e guarda tóxico e na posse de maquinismo para manipular entorpecente”. (“Lei de Drogas Comentada”, Ed. RT, 2ª edição, p. 200).

A jurisprudência não discrepa deste entendimento:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E GUARDA DE MAQUINÁRIO E DE ESTOCAGEM DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADOS À MANUFATURA DE ENTORPECENTES (ARTS. 12, § 1º, I, e 13 DA LEI Nº 6.368/76, ATUALMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 33, § 1º, I, e 34, DA LEI Nº 11.343/06). CONDUTAS TÍPICAS QUE CONSTITUEM MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO DE DELITO DE ALCANCE MAIS AMPLO (FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio da consunção em relação aos crimes de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria-prima destinados à manufatura de substâncias entorpecentes pode ser aplicado, uma vez que ditas condutas constituem meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, a fabricação de entorpecente. 2. Conclui-se que o intuito do legislador foi punir, por exemplo, o agente que constrói um laboratório para refino de cocaína, independentemente da sua efetiva produção, ainda que a posse das máquinas e dos objetos em questão não seja, isoladamente, considerada ilícita (tais como, no caso em exame, de baldes e de um liquidificador); ou sancionar aquele que mantém em depósito matéria-prima destinada ao refino ou à produção de drogas, mesmo que a estocagem dessa, por sua natureza, não constitua, per se, crime (no caso concreto, de solução de baterias, livremente revendida com fim específico de regeneração de cargas elétricas em baterias, e de barrilha, utilizada no tratamento de água para piscinas e para outras finalidades lícitas). 3. No caso em exame, pelo que se vê da denúncia, tanto a posse da

matéria-prima, como a dos maquinismos/objetos, visava a um fato único: a produção de entorpecente (merla) pelo paciente naquele local, para posterior comercialização da droga. 4. Está patente nos autos a existência de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de fabricação. 5. Ordem concedida." (HC 100.946/GO, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. 25/10/2011, DJe 27/02/2012).

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DE REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. PLEITOS INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS NORMAS VIOLADAS. RECURSO ESPECIAL COM MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PEDIDOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA PROVIDÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. POSSE DE INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4. BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA CIRCULAR. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 2. É assente nesta Corte Superior que cabe ao aplicador da lei, nas instâncias ordinárias, proceder ao cotejo do material fático-probatório dos autos, a fim de aferir a existência de provas aptas a embasar a condenação bem como a correta dosimetria da pena, com incidência das causas de aumento e de diminuição que ficarem comprovadas. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via eleita, o reexame de fatos e provas, conforme dispõe o enunciado nº 7 da Súmula desta Corte. 3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas. (REsp 1196334/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).

Vê-se, então, que em situações como esta dos autos, em que são apreendidas substâncias entorpecentes, petrechos e matéria prima destinados à preparação de drogas dentro do mesmo contexto fático, aplica-se o princípio da consunção, impondo-se a condenação do acusado apenas pelo crime de tráfico de drogas.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais (fls. 39/40). Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, ele estava na posse de elevada quantidade de entorpecente e de natureza nefasta, ou seja, 01 (uma) porção de cocaína, com cerca de 4.700,0g; 02 (dois) tijolos de “maconha”, com cerca de 607,0g; e, mais 01 (uma) porção de “maconha”, com cerca de 20,0g). A natureza do entorpecente, cocaína, também vem seu desfavor, diante do grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Ausentes atenuantes e agravantes. Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo que não estão preenchidos todos os requisitos para a benesse legal. O acusado, apesar de ser primário e de bons antecedentes, tinha plena consciência de estar contribuindo para organização voltada para o tráfico de entorpecente, sobretudo diante da elevadíssima quantidade de drogas apreendidas em sua residência e materiais destinados ao embalo. Ora, só quem goza de confiança dos demais membros da organização tem a tarefa de guardar tamanha quantidade de drogas em casa, prepará-la e abastecer a biqueira, até mesmo porque sabe-se do valor econômico deste material. Não seria destinada esta função para o iniciante, o desconhecido, aquele que não tem nenhum conhecimento da vida do tráfico, o que revela que ele estava integrado neste ambiente odioso. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra “Lei de Drogas Comentada”, ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que “o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico”.

O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o criminoso que comercializa grande quantidade de entorpecente não faz jus ao redutor legal, dada a evidência do seu envolvimento em atividades criminosas. Trago à colação: “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA CONCRETIZADA: 7 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. APREENSÃO DE 157,3 KG DE MACONHA. PENA BASE DE 8 ANOS JUSTIFICADA. ELEVADA CULPABILIDADE PELA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o. DA LEI 11.343/06 EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA, TODAVIA, QUE INDICA A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. É certo que todas as funções processuais penais são de inescandível relevância, mas a de denunciar, a de aceitar a denúncia, a de restringir prematuramente a liberdade da pessoa, a de julgar a lide penal e a de dosimetrar a sanção imposta exigem específico trabalho intelectual de esmerada elaboração, por não se tratar de atos burocráticos de simples ou fácil exercício,

mas sim de atividade complexa, em razão de percutirem altos valores morais e culturais subjetivos a que o sistema de Direito confere incontornável proteção. 2. Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda que se retire a menção aos maus antecedentes e, portanto, se reconheça a primariedade do paciente, não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que extremamente elevada a culpabilidade em razão da quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade da droga indica sua participação em organização criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (STJ, HC 140.211/MS, 5ª turma, Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.09.2009) (grifei).

Assim, afastada a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, as penas ficam fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, e artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, considerando a reprovabilidade elevada da conduta, frente à natureza e quantidade de entorpecente apreendida, revelando que o regime mais gravoso é o mais eficiente para prevenção e reparação do crime.

De se esclarecer que atualmente não existe mais a obrigatoriedade da fixação do regime mais gravoso, como previa a lei, mas nada impede que no caso em concreto o Juízo entenda por aplicá-lo, por se tratar mais apropriado à espécie, sempre com vistas à efetiva prevenção e reparação do crime.

Não há como mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a do tráfico ilícito de drogas. Trata-se de delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.

Em que pese sua primariedade, a quantidade de entorpecente apreendida é muito elevada, e o acusado, com sua conduta, contribuiu fortemente com a disseminação de drogas nesta cidade, a exigir maior rigor do Estado.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos". (HC nº 315.829/MG T6 Sexta Turma - Rel. Ministro Ericson Marinho J. em 26.5.2015 Dje em 5.6.2015).

Pelo mesmo fundamento, incabível falar-se em substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois os requisitos legais não estão satisfeitos. A quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis vedam a concessão do benefício.

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação lícita, ao contrário, declarou ser dedicado ao vício em entorpecente. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas, certamente voltará a delinquir. Necessário,

assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar MAYCON HENRIQUE FAVARELLI, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o dos crimes previstos nos artigos 33, §1º e 34 da mesma Lei, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Fixo os honorários do patrono no máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeçam-se certidões.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois proveito do crime em apreço, bem assim declaro o perdimento do veículo apreendido às fls. 20, pois é instrumento do crime. Autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Drogas.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA